

1502084-27.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2247384/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO BORGES JUNQUEIRA DE PAULA E SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

GUSTAVO BORGES JUNQUEIRA DE PAULA E SILVA foi denunciado como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502084-27.2021.8.26.0530 - controle nº 2021/000888

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2247384/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO BORGES JUNQUEIRA DE PAULA E SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

GUSTAVO BORGES JUNQUEIRA DE PAULA E SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 33, §1º, II, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia, horário e local descritos na denúncia foi surpreendido guardando e cultivando

plantas de droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, consistente em "Cannabis sativa L", vulgo "maconha".

Narra a denúncia que policiais militares foram acionados para atendimento de suposta ocorrência de furto à residência situada no local dos fatos, pois uma vizinha do acusado relatou que o portão, que a guarnece, estava aberto.

Ao ingressarem no interior do imóvel, os referidos agentes encontraram uma plantação de "maconha" em espécie, bem como quantidades de "maconha" prensada e "maconha" seca, além de uma estrutura, consistente em climatizadores, balança de precisão, rolos de plástico-filme, medidores de pH e termômetro digital, própria para a produção e embalo do aludido entorpecente.

Os policiais militares verificaram ainda existirem poucos móveis no interior da residência.

Dispensada a realização de audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM 2548/2020, Comunicado CG 232/2020, ambos deste E. Tribunal de Justiça, e Recomendação 62/2020, do E. Conselho Nacional da Justiça, como medida profilática a evitar a disseminação do denominado Covid-19, o acusado teve sua prisão em flagrante relaxada, nos termos do artigo 310, inciso I (págs. 80/84).

Pessoalmente notificado (pág. 137), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 127/132) e a denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 10 de fevereiro de 2022 (págs. 146/147).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Debates realizados, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia e, na dosimetria, posicionou-se pela fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do tráfico privilegiado, com a imposição de regime semiaberto, além também do confisco dos bens apreendidos e destruição da droga.

A Defesa requereu a desclassificação da conduta para o artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, tecendo considerações de que a polícia não o surpreendeu traficando e sim só esteve na residência em decorrência de denúncia anônima, no período noturno; subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, com a imposição de regime prisional aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no laudo de constatação provisória (págs. 44/46) e no exame químico-toxicológico (págs. 105/107) a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica

TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L (maconha), em 37,980g, desprovido de invólucro individual; 94,690g desprovido de invólucro individual; 55 mudas de plantas compostas por raiz, caule e folhas de aproximadamente 10cm de comprimento cada uma e juntas apresentavam massa de 5,430g; 03 plantas compostas por caule e folhas de aproximadamente 76cm de comprimento e massa de 549,790g; além de, segundo laudo pericial de págs. 103/104, 01 balança digital; 01 rolo de plástico tipo filme; 01 embalagem com a logomarca Seedsman®, relacionada com sementes de Cannabis, vazia; 02 rótulos com as logomarcas Cannabis - Super Lemon Haze Auto®; 01 termômetro digital; 02 medidores de pH das marca ATC®, cor amarela e Hanna®, cor vermelha; e dois medidores de pH de solo da marca Amtast®.

Rafael Sizenando Armellino, policial militar, recordou que, por denúncia anônima, o COPOM noticiou a ocorrência de furto em razão de o portão do imóvel estar aberto e o morador ausente; no local, relatou haver constatado as portas abertas e, ao entrar, deparou-se com plantas pequenas, grandes, estufas, vários petrechos para cultivo e também da própria droga já preparada para consumo; enquanto saía da residência para notificar o COPOM do que realmente se tratava, mencionou ter o acusado chegado, o qual, indagado, afirmou ser para seu consumo pessoal.

Prosseguiu o policial Rafael com a descrição de que a casa era composta por três quartos: no dos fundos nada havia de móveis, somente os pés pequenos de maconha, no

do meio os pés grandes de maconha e, no terceiro, tão somente uma cama, ao passo que na sala apenas madeiras no chão e na cozinha a geladeira e uma mesa; ponderou que o imóvel não aparentava local de moradia, utilizado só para cultivo da droga, embora encontrados, em um dos quartos, documentos que correspondiam ao acusado. Yago Nycholas de Almeida Malta, também policial militar, a par das informações prestadas por seu parceiro de corporação acima inquirido, reforçou que vizinho acionou o COPOM porque o portão basculante e a porta da sala encontravam-se totalmente abertos; no período noturno, ao ingressar no imóvel, declarou ter a equipe constatado tratar-se de local utilizado para cultivo de maconha, com estrutura climática e de refrigeração próprios a tanto.

O policial Yago seguiu comentou que, durante a diligência, o morador chegou assumindo a posse da droga, sob a alegação de ser para seu consumo pessoal; detalhou que nos quartos o acusado mantinha estufa com ar-condicionado, controle de temperatura e umidade apropriados ao cultivo da droga; complementou que a casa tinha poucos móveis, bem vazia, com geladeira na cozinha; mencionou que os vizinhos relataram ser o acusado novo morador da rua, não o conheciam, sequer tinham seu contato telefônico ou quaisquer outras informações a ele relacionados.

Interrogado, o acusado alegou ter acabado de se separar e morava há não mais de um mês na residência; disse cultivar maconha já há um ano para seu consumo pessoal (é usuário desde os 14 anos de idade e consome aproximadamente de 35g a 40g semanais, "fumando" diariamente de 3 a 4 "baseados"), para não ter de se envolver com ambientes relacionados ao tráfico; asseverou que seu portão abriu sozinho e os vizinhos, com suspeitas, ligaram para a proprietária do imóvel que até tentou contato, mas não conseguiu respondê-la, pois naquele instante encontra-se em seu estúdio de tatuagem, com celular sem bateria e quando retornou no local foi surpreendido com a presença dos policiais.

O acusado explicou que a estrutura montada era pequena, composta por ar-condicionado, umidificador e luzes, guardando relação com o chamado cultivo indoor, que não serve apenas para maconha; justificou que as mudas seriam oriundas de falha de cultivo anterior que resultaram em sementes irregulares, sendo que, em condições comuns, 25% delas são fêmeas, as produtivas, enquanto machos são dispensadas e, por isso, somente aproveitaria cinco das plantas, no máximo, porque também depois de secas só se consegue extrair de cada pé em torno de 20g.

O acusado completou com a observação de que na sala estavam as caixas de móveis recém-comprados pela internet para ainda serem montados; afirmou que a balança de precisão ficava dedicada à pesagem de fertilizantes em pó, embora também a aplicava para saber quanto resultava de sua colheita, ao passo que o plástico filme era empregado para uso geral da casa, às vezes também para guardar sua própria droga; esclareceu ter trabalhado 10 anos em empresa na qual exercia a função de controlador de pragas, com entendimento, dentre outros, em plantas e produtos químicos.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu em parte na prática delituosa narrada na denúncia.

Do que se colhe da narrativa dos policiais, a diligência no imóvel decorreu de denúncia anônima comunicada por vizinhos que teriam suspeitado das condições do imóvel, com portão e porta às escâncaras estando ausente o morador, daí então, ante fundadas razões de ocorrência de crime em flagrante delito, a equipe teve a surpresa de se deparar com estrutura montada na residência para o cultivo de maconha, incluindo a droga já preparada para consumo.

O crime em debate enquadra-se como crime permanente, em função do qual, somado a todos os elementos trazidos, torna dispensável a expedição de mandado de busca domiciliar, a exemplo do aresto do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de

tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. [...] 5. Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Publicação: 10/05/2017). Ainda que assim não fosse, poder-se-ia reputar como presente o fenômeno da serendipidade ou encontro casual/fortuito de provas ou, ainda, em alemão, Zufallsfunden, consolidado na jurisprudência: [...]

IV - Não há se falar em desvio de finalidade da diligência de exploração de local realizada pela Polícia Federal quando, tangenciando-se a linha normal de desdobramentos de uma investigação, depara-se com elementos que podem servir de base para outras investigações ou aprofundamento da investigação em curso, no que a doutrina denomina de 'serendipidade' (precedentes). [...] (STJ, HC 324.946/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017; DJe de 01/08/2017) A isso deve ser acrescido que, não obstante as conclusões lançadas por ocasião da audiência de custódia que conduziram ao relaxamento da prisão em flagrante do acusado (págs. 80/84), não há vinculação quer ao titular da ação penal, quer a servir de suporte de valoração sobre a validade ou não das provas, na esteira já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE RECONHECIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO ILEGAL. JUÍZO DE VALOR SOBRE AS PROVAS OBTIDAS. IMPOSSIBILIDADE. FASE PRÉ-PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA. ATUAÇÃO LIMITADA À REGULARIDADE DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A decisão proferida durante a audiência de custódia, ao relaxar a prisão em flagrante da recorrente, independentemente dos motivos que determinaram a concessão da liberdade, não vincula o titular da ação penal, e, portanto, não obsta o posterior oferecimento de denúncia, sob pena de negativa de vigência ao art. 24 do Código de Processo Penal." (RHC 85.970/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018).

2. A audiência de custódia não se presta à incursão no mérito de futura ação penal, por isso, magistrado designado para a sua realização, exceto para fins relacionados única e exclusivamente à prisão, não possui competência para emitir juízo de valor sobre validade ou não de provas.

3. Agravo desprovido.

(AgRg no RHC 127.436/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Vertida a análise ao mérito, não se alcançam evidências da prática criminosa assestada na denúncia, eis que, desde o princípio, o acusado, em fase extrajudicial, declarou ser "usuário de maconha, que consome por semana em torno de 30 gramas de maconha por semana, que adquiri a semente em banco de semente pela internet, que os sites em que compra são de outro país; que chega normalmente por correio e nunca teve problemas com a compra; que faz o cultivo a aproximadamente um ano, que prefere cultivar a comprar de outra pessoa, e que comprou equipamento para fazer o cultivo da maconha; que fuma maconha desde os 13 anos de idade, por fim alega que o cultivo é somente para seu uso, que não faz a venda, nem entrega para outra pessoa" (pág. 5).

Diante de tais termos, verifica-se que a apreensão recaiu sobre o total de 132,67g da droga in natura, de maconha pronta para consumo, ao passo que o restante guarda relação com as mudas que constituem etapa, é bem verdade, ao preparo, na condição de insumos à produção da maconha.

Analisada a primeira parte do parágrafo logo acima, o acusado disse consumir, semanalmente, 35g a 40g da monodroga em questão, compatível com a média de consumo avaliada por estudos científicos:

[...]

No trabalho "Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátricos: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos", de Paulo Borini e

outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína. (TJSP; Revisão Criminal 0025831-60.2017.8.26.0000; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 1º Grupo de Direito Criminal; Foro de Igarapava - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)

A droga já em condições de consumo apreendida, no total de 132,67g, demandaria, em cálculos aproximados, demandaria pouco mais de três semanas para se esgotar, não representando, portanto, proporção que, logo de plano, pode-se atestar suficiente a terceiras pessoas, por só esse fator quantitativo, pois não se teve nenhum valor em dinheiro encontrado, seja no imóvel, seja com o próprio acusado.

Já no tocante às mudas das plantas, não é inverossímil a fala do acusado ao dizer que o aproveitamento seja baixo por oportunidade da extração na colheita.

Neste particular, oportuno colacionar trecho do REsp n. 1.675.709/SP, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 13/10/2017, no qual exposta a conclusão de pesquisa científica realizada por peritos criminais federais acerca do processo de plantio da Cannabis sativa Linneu, verbis:

[...] Segundo estudo realizado pelos peritos criminais federais Rafael S. Ortiz e Monique dos Reis, com as alunas do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é baixíssima a probabilidade de uma semente germinar e vir a gerar as flores (parte utilizada para o consumo na forma fumada ou para produção do óleo medicinal). Confira-se:

(...)

No estudo acima ilustrado, foram utilizadas 73 amostras de sementes (frutos aquênios de Cannabis sativa Linneu) tratadas em condições semelhantes de germinação, fertilização e estufa preparada para a operação, à semelhança do que fazem os cultivadores em geral. Ainda assim, após 12 semanas, tempo considerado suficiente para a “colheita” das flores, restaram apenas 5 amostras aptas à produção da droga, ou seja, apenas 6,85% do total das sementes plantadas, sem contar que tal percentual pode ser ainda menor, visto que são apenas as plantas fêmeas que produzem as flores (“buds”), parte utilizada para o consumo na forma fumada ou cocção para extração do óleo medicinal.

São dados a serem considerados para o caso concreto, mormente porque examinados os aspectos subjetivos do acusado, o conhecimento ao cultivo advém da prática de trabalho realizado em empresa na qual exercia a função de controle de pragas, conforme contrato laboral de pág. 74 e, ao que consta, segundo os próprios vizinhos consultados pela equipe policial, o acusado há pouco tempo morava no bairro, conforme ele próprio afirmou em juízo, sendo que o policial Rafael chamou atenção para o fato de que em um dos quartos encontrou documentos pessoais relacionados ao acusado, além de também estar o imóvel guarneado por cama, geladeira e mesa de cozinha, indicativos que servem ao menos de indício a ali se constituir ambiente de moradia, sem existir qualquer informe prévio da prática de tráfico de drogas, mesmo porque a motivação da diligência era, a princípio, vocacionada à apuração da prática de furto.

Tampouco a balança digital e o plástico filme se prestam a estabelecer compreensão contrária, conforme as ponderações acima já lançadas, pois destituídos, tais petrechos, de per si, de elementos de emprego ao tráfico, sobretudo diante da circunstância de terem sido apreendidas 01 embalagem com a logomarca Seedsman®, relacionada com sementes de Cannabis, vazia; 02 rótulos com as logomarcas Cannabis – Super Lemon Haze Auto®; 01 termômetro digital; 02 medidores de pH das marca ATC®, cor amarela e Hanna®, cor vermelha; e dois medidores de pH de solo da marca Amtast®, que se harmonizam ao cultivo indoor apresentado pelo acusado, cujas sementes, ditas de frutos aquênios, já serviram de base ao reconhecimento de atipicidade da conduta, no AgRg no AREsp 1076132/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/04/2018.

Frente a todas essas considerações, para o caso dos autos a hipótese que melhor se

amolda é a da desclassificação da conduta para o crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Não se trata de ingenuidade a dúvida ora posta em consideração, mas não se vê com a clareza necessária exigida para a condenação a conclusão segura formulada pela acusação. O precedente a seguir ilustra situação similar:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Suspeita. Fica a impressão de que o réu é traficante, mas a simples suspeita não pode gerar condenação, porque duvidosas a autoria e a materialidade do delito (RJTJRGs 132/160), apud “Código de Processo Penal e sua interpretação jurisprudencial”, Coordenação de Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora Revista dos Tribunais, 1999, vol.2, p.1.890.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado, em homenagem ao princípio in dubio pro reu.

Destarte, embora não se possa atribuir ao acusado a prática do tráfico de drogas, é certo que confessou ele a posse das porções de maconha já prontas, cuja destinação seria o consumo pessoal, também passível de reprovabilidade sob a jurisdição penal. O acusado ostenta bons antecedentes, a se afigurar suficiente a imposição da pena de advertência sobre o efeito das drogas, prevista no artigo 28, inciso I, Lei nº 11.343/2006, considerando o caráter de prevenção especial da sanção penal que deve desestimular o acusado à prática do delito.

O uso de drogas continua sendo crime, porém, não há de se aplicar pena diversa em razão de a medida aplicada consistir em caráter educativo para que o agente possa se recompor socialmente, com consciência da ilicitude de sua conduta e oportunidade para se submeter a tratamento de desintoxicação.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido e, em consequência, condeno GUSTAVO BORGES JUNQUEIRA DE PAULA E SILVA, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006.

Diante do resultado aqui alcançado, comunique-se a autoridade policial a autorização da restituição dos medidores de pH, do rolo de embalagem plástica, da balança e do rótulo, a serem retirados pelo acusado, em caso de interesse, nos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado; em caso de inércia, fica determinado à autoridade policial, desde já, a depender do estado de conservação, e porque inservíveis e inexpressivos economicamente, promover, se o caso, as respectivas destruições.

Transitada em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA